

1500501-08.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... no aparelho conteúdo relacionado ao tráfico de drogas.

De qualquer forma, não se imputa ao acusado a utilização do celular na execução do crime.

Impossibilidade de desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por estar evidenciado o tráfico de drogas, fica logicamente afastada a possibilidade de desclassificar a conduta para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500501-08.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500501-08.2022.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Walisson Vinicius de Souza Matos Pereira

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

WALISSON VINÍCIUS DE SOUZA MATOS PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de junho de 2022, por volta das 09h03, na Rua Sebastião Paque Rosilho, num terreno situado no nº 315 e em outro terreno vizinho, Jardim Planalto, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros:

- a) 65 (sessenta e cinco) porções de maconha, com massa líquida total de 192,16g (cento e noventa e dois gramas e dezesseis centigramas), embaladas em invólucros do tipo zip;
- b) 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, com massa líquida total de 42,7g (quarenta e dois gramas e sete decigramas), embaladas em invólucros do tipo zip;
- c) 02 (duas) porções de maconha, com massa líquida total de 358,32g (trezentos e cinquenta e oito gramas e trinta e dois centigramas), embaladas em invólucros da

cor preta;

d) 05 (cinco) porções de maconha, com massa líquida total de 150,48g (cento e cinquenta gramas e quarenta e oito centigramas), embaladas em invólucros plásticos do tipo filme; e

e) 06 (seis) porções de cocaína, na forma de crack, com massa líquida total de 56,61g (cinquenta e seis gramas e sessenta e um centigramas), embaladas em invólucro plástico.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o réu tinha em depósito as porções de crack, maconha e cocaína, que se destinavam ao consumo de terceiros.

Após receberem notícia de que um indivíduo conhecido como Gordinho, de nome Walisson, estava no local do fato, embalando drogas para a venda, policiais direcionaram o patrulhamento para lá.

Quando chegaram, viram o denunciado manipulando um objeto. Ao perceber a presença de policiais, o réu tentou empreender fuga, mas foi contido.

No local onde Walisson manipulava algo, os milicianos encontraram 65 (sessenta e cinco) porções de maconha, com massa líquida de 192,16g (cento e noventa e dois gramas e dezesseis centigramas); 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, com massa líquida de 42,7g (quarenta e dois gramas e sete decigramas); 05 (cinco) porções de maconha, com massa líquida de 150,48g (cento e cinquenta gramas e quarenta e oito centigramas); 06 (seis) porções de cocaína, na forma de crack, com massa líquida de 56,61g (cinquenta e seis gramas e sessenta e um centigramas); 02 (duas) balanças de precisão; várias embalagens plásticas destinadas ao acondicionamento de substâncias entorpecentes; e 02 (duas) facas.

Como os policiais tinham informação de que o denunciado também tinha substâncias entorpecentes em depósito em um terreno vizinho, realizaram buscas naquele imóvel, com auxílio de cão farejador, e lá encontraram outras 02 (duas) porções de Cannabis sativa Lineu, com massa líquida total de 358,32g (trezentos e cinquenta e oito gramas e trinta e dois centigramas).

Indagado, o réu declarou que estava soltando pipa no local do fato. Entretanto, nenhum item relacionado àquela prática foi encontrado lá.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação das substâncias entorpecentes à comercialização.

A denúncia (fls. 144/147) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/139) e foi recebida em 28 de julho de 2022 (fls. 161).

Citado (fls. 199), o réu, assistido por Defensor constituído (fls. 125), apresentou resposta à acusação (fls. 204/209).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 214).

Reexaminada a presença dos requisitos legais, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código Penal, manteve-se a prisão preventiva (fls. 231).

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 237/238).

O Defensor juntou links de gravações audiovisuais (fs. 240).

Nas alegações finais, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 243/254).

O Defensor, na sua manifestação final, postulou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06; pela aplicação da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06; e pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 263/283).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/06) e de exibição e apreensão (fls. 29/30), pelo laudo de exame

químico toxicológico (fls. 126/129), pelos laudos de exame de objetos apreendidos (fls. 131/134 e 149/159) e pela prova oral, colhida sob o contraditório. Os relatos orais evidenciaram a autoria da infração penal.

Relatos orais.

A testemunha Henrique Magalhães Ramos (fls. 237/238), policial militar, informou que compareceu ao local do fato, após receber notícia de que o acusado estava a embalar drogas lá. Quando chegaram, ainda do interior da viatura, viram o denunciado abaixado no interior do terreno, manuseando algo. Ao perceber a chegada da viatura, ele pulou um muro, saiu do terreno e tentou fugir. Contudo, foi detido, já na via pública. Em seguida, vistoriaram o local onde o réu estivera abaixado e lá encontraram porções de crack, 29 porções menores de cocaína, 05 porções maiores de cocaína, 65 porções menores de maconha, 05 porções maiores de maconha, balanças de precisão e duas facas. Como havia notícia de que havia drogas em terrenos próximos, realizaram buscas nas imediações, com auxílio de cão farejador. A 40m ou 50m de distância do local onde o réu estivera abaixado, encontraram outras porções de maconha. Na ocasião do fato, o réu declarou que estava soltando pipa no terreno. Contudo, não encontraram, sob a posse dele, nenhum objeto relacionado àquela atividade. Segundo usuários de drogas daquela região, o réu estava dominando o tráfico no bairro. De acordo com informantes, Walisson apenas embalava as drogas e terceiros as comercializavam. Informou que o terreno é irregular e a face interna é baixa, mas a face externa é relativamente alta. Declarou que, da rua, pessoas desatentas não conseguiriam visualizar o réu. Contudo, a viatura que ocupavam, modelo Trailblazer, é alta. Por isso, conseguiram vê-lo. Disse não saber se o segundo conjunto de maconha, encontrado em outro terreno, também pertencia ao réu. A testemunha Anderson Luiz Ferreira de Souza (fls. 237/238), também policial militar, informou que a testemunha Henrique Magalhães Ramos recebera notícia de que Walisson embalava drogas num terreno próximo à residência dele. Na data do fato, foram ao local indicado pelo informante e viram o réu no interior do terreno. Ele tentou fugir pelos fundos, mas foi abordado. A princípio, não encontraram nada sob a posse dele. Contudo, no local onde ele anteriormente estivera abaixado, encontraram porções de crack, maconha e cocaína, muitas embalagens e balanças de precisão, ainda ligadas. Indagado, Walisson alegou que estava soltando pipa, contudo, não portava nem linha, nem pipa. Como o denunciante dissera que ele também guardava drogas em outro terreno, nas imediações, realizaram buscas com cães e encontraram outros dois pacotes de maconha. Em seguida, Walisson recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia. Disse que não conhecia o denunciado anteriormente ao fato. Declarou que, quando passaram defronte ao terreno, Walisson tentou se abaixar, para se esconder. Depois, ao perceber que desembarcariam, tentou fugir. Informou que o terreno tem vegetação relativamente alta e fica acima do nível da rua, em área residencial. Disse considerar o muro do terreno alto, mas ressaltou que parte dele está quebrada, formando uma escada. Asseverou que Walisson residia a aproximadamente um quarteirão de distância do local do fato. Interrogado (fls. 237/238), o réu negou a prática do crime. Disse que estava defronte à sua casa, soltando pipa. Ao ver uma pipa indo embora, montou na motocicleta de sua genitora e dirigiu-se ao local do fato, para procurá-la. Declarou que o local dista aproximadamente três ou quatro quarteirões de sua casa. Na ocasião da abordagem, estava procurando linha ou pipa no interior do terreno, quando viu os policiais descendo, desembarcando da viatura, com armas em punho. Afirmou que estava em pé quando os policiais o viram. Como cumpria pena em regime aberto, assustou-se e correu para a calçada, onde foi abordado. Negou que tenha corrido para os fundos do terreno. Ao ser abordado, explicou que estava procurando uma pipa. Algum tempo depois, sua mãe compareceu ao local e o interrogando foi posto numa viatura. Em seguida, eles acionaram a equipe do canil, realizaram buscas em outro terreno e voltaram com uma sacola de drogas. Negou que as drogas estivessem sob sua posse. Afirmou que os fatos ocorreram numa quarta-feira, no aniversário de sua filha. Disse que não trabalhara na semana do fato, porque era aniversário da sua filha. Afirmou que estava em liberdade havia aproximadamente um ano e um mês. Disse que foi condenado anteriormente pela prática de crime de tráfico, mas não portava drogas na ocasião de sua prisão anterior. Informou que sua

prisão anterior foi executada por outros policiais. Salientou que conhecia o policial Anderson, por fato ocorrido durante sua adolescência.

Laudo de exame químico toxicológico (fls. 126/129).

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 126/129) demonstra a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (fls. 29/30) e descreve suas quantidades. Segundo o laudo, constatou-se que os fragmentos vegetais embalados em 65 invólucros do tipo zip continham Tetrahydrocannabinol (fls. 127, item 1); que os materiais sólidos embalados em 34 invólucros do tipo zip continham cocaína (fls. 127/128, item 2); que os fragmentos vegetais embalados em 02 invólucros da cor preta continham Tetrahydrocannabinol (fls. 128, item 3); que os fragmentos vegetais embalados em 05 invólucros de plástico filme continham Tetrahydrocannabinol (fls. 128, item 4); e que os materiais petrificados embalados em 06 invólucros plásticos continham cocaína (fls. 128/129, item 5).

Laudo de exame de objetos apreendidos (fls. 131/134).

Além das drogas acima descritas, apreenderam-se duas balanças, duas facas e saquinhos com fechamento do tipo zip (fls. 29/30).

Aqueles peças foram submetidas a exame, cujos resultados estão detalhados no laudo de (fls. 131/134).

Segundo o laudo, todas as peças continham vestígios de Tetrahydrocannabinol.

As balanças e os saquinhos plásticos do tipo zip também continham vestígios de cocaína.

Gravações audiovisuais contidas nos links de fls. 240.

Os hyperlinks de fls. 240 remetem a duas gravações audiovisuais.

Em um dos vídeos, de 50 segundos de duração, observa-se, em primeiro plano, uma mulher de cabelos negros sentada no meio-fio do passeio público. Ao fundo, homens fardados, aparentemente policiais militares, caminham em meio à vegetação, juntamente com um cão.

No outro vídeo, de quinze segundos de duração, observa-se, em primeiro plano, uma mulher de cabelos loiros sentada no meio-fio do passeio público. Ao fundo, um homem fardado, aparentemente policial militar, caminha da vegetação para a via pública. Entretanto, não se produziram provas sobre as circunstâncias de produção das gravações audiovisuais. Isto é, não há elemento de prova sobre a data, horário e local em que foram produzidas, nem sobre a identidade das pessoas que tiveram suas imagens capturadas, tampouco sobre o que faziam.

Fotografias incorporadas às alegações finais defensivas (fls. 269/271 e 273/274).

No corpo das alegações finais, o Defensor incluiu imagens diversas (fls. 269/271 e 273/274).

Segundo a argumentação do Defensor, as imagens retratam diferentes ângulos do local do fato e suas imediações, e uma delas contém recorte de um dos vídeos de fls. 240. Distinção entre objeto de prova e elemento de prova.

A produção probatória tem como objeto proposições de fatos apresentadas pelas partes. Leia-se:

O objeto de prova (thema probandum) “é determinado pelas proposições representativas do fato juridicamente relevantes, e colocadas pelas partes como base da acusação e da defesa, ou mesmo como fundamento de eventual pesquisa judicial”.

Portanto, segundo o conceito anterior, objeto de prova refere-se a proposições representativas do fato e não ao próprio fato, ou seja, é equivocado afirmar que a prova destina-se a obter conhecimento sobre um fato, pois “o que se apura no processo é a verdade ou a falsidade de uma afirmação sobre um fato”. (Fernandes, Antonio Scarance et. al. Coord. Provas no processo penal: estudo comparado. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 10).

Assim, por exemplo, a afirmação contida na denúncia, de que o acusado tinha em depósito porções de maconha crack e cocaína, é uma proposição representativa de fato, ou seja, objeto de prova.

Do mesmo modo, a afirmação contrária, de que o réu não tinha em depósito porções de maconha, é uma proposição representativa de fato. Portanto, trata-se de objeto de prova.

Com a finalidade de confirmar ou negar uma proposição, as partes, ao longo do

processo, produzem elementos de prova:

(...) na terminologia processual, denomina-se elemento de prova (evidence), quando o vocábulo “prova” referir-se aos “dados objetivos que confirmam ou negam uma asserção sobre determinado fato que interessa à decisão da causa”. Apresentam-se os seguintes exemplos de elemento de prova: a declaração de uma testemunha quanto ao fato ocorrido, a opinião de um perito sobre a matéria de sua especialidade, o conteúdo de um documento. (Fernandes, Antonio Scarance et. al. Coord. Provas no processo penal: estudo comparado. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 10).

Relatos e laudos de pessoas que presenciaram o fato ou examinaram seus vestígios (testemunhas e peritos), bem como vestígios em si (documentos, fotografias e vídeos) são elementos de prova.

No caso sob análise, os vídeos e as fotografias (fls. 240, 269/271 e 273/274) seriam elementos de prova.

As manifestações do Ministério Público e do Defensor sobre as circunstâncias de um determinado fato são proposições, isto é, objetos de prova.

Insuficiência das manifestações do Defensor para demonstrar o conteúdo e as circunstâncias de produção dos vídeos (fls. 240) e das fotografias (fls. 269/271 e 273/274).

Nas alegações finais, o Defensor apresentou afirmações (proposições, objeto de prova) sem suporte em elementos de prova.

Afirmou, por exemplo, que fotografias contidas no corpo da manifestação final retratam o muro do terreno onde o réu foi visto por policiais militares (fls. 271).

As fotografias de fls. 271 são elementos de prova. A manifestação do Defensor, no sentido de que retratam o local do fato, são objeto de prova.

Ainda segundo o Defensor, um dos vídeos retrata a testemunha Anderson saindo de outro terreno, com uma sacola preta onde estariam as drogas (fls. 273).

As asserções de que aqueles vídeos (fls. 240) retratam parte das buscas policiais narradas na inicial acusatória, de que aquele indivíduo é uma das testemunhas e de que porta uma sacola são meros objetos de prova.

Entretanto, não se produziram elementos de prova concernentes ao momento e ao local onde o vídeo foi gravado, sobre quem são as pessoas filmadas, nem sobre o que faziam.

Note-se, as afirmações do Defensor (fls. 273) não elucidam as circunstâncias de produção dos vídeos, pois são meras proposições, objetos de prova.

Como as manifestações do Defensor são proposições, objetos de prova, nada esclarecem sobre as circunstâncias de produção dos vídeos e das fotografias.

Princípio da autorresponsabilidade das partes.

A instrução probatória tem função retrospectiva. Por meio das provas, busca-se reconstruir o passado, com tanta precisão quanto possível. Sobre o tema, leia-se o texto de Aury Lopes Jr:

O processo penal é um instrumento de retrospecto, de reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Como ritual, está destinado a instruir o julgador, a proporcionar o conhecimento do juiz por meio da reconstrução histórica de um fato. Nesse contexto, as provas são os meios através dos quais se fará essa reconstrução do fato passado (crime). O tema probatório é sempre a afirmação de um fato (passado), não sendo as normas jurídicas, como regra, tema de prova (por força do princípio *iura novit curia*).

(...)

O processo penal, inserido na complexidade do ritual judiciário, busca fazer uma reconstrução (aproximativa) de um fato passado. Através – essencialmente – das provas, o processo pretende criar condições para que o juiz exerça sua atividade cognitiva, a partir da qual se produzirá o convencimento externado na sentença. É a prova que permite a atividade cognoscitiva do juiz em relação ao fato histórico (story of the case) narrado na peça acusatória. O processo penal e a prova nele admitida integram o que se poderia chamar de modos de construção do convencimento do julgador, que formará sua convicção e legitimará o poder contido na sentença.

(LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 13ª ed. ebook, São Paulo: Saraiva, 2016. p. 400).

Como o conhecimento do juízo sobre o fato decorre das provas, a perfeita cognição

somente é possível se essas forem minimamente fidedignas. Ou seja, só é possível reconstruir o passado, se for possível confiar nas provas trazidas aos autos. Colocada essa premissa, de que as provas somente se prestam à reconstituição do passado se forem fidedignas, consigno que a atividade probatória é precípua das partes. Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe à parte que a fizer.

Logo, cabe às partes trazerem elementos de prova fidedignos, que permitam a adequada reconstrução do crime, enquanto fato histórico.

Por decorrência do princípio probatório da autorresponsabilidade das partes, essas assumem as consequências das provas que produzem ou deixam de produzir. Leia-se: As partes assumem as consequências de sua atividade ou inatividade probatória. Em outras palavras, por conta desse princípio, as partes assumem as consequências de sua inatividade, erro ou negligência, em relação à prova de suas alegações.

Exemplificando, na hipótese de processo penal por crime de ação penal pública, caso o Ministério Público não comprove a prática do fato delituoso, a consequência será a absolvição do acusado. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 4. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1281, sem sublinhas no original).

Consoante se expôs anteriormente, a cognição do fato somente é possível se as provas forem fidedignas e compete às partes trazê-las aos autos.

Por força do princípio da autorresponsabilidade, a construção de conjunto probatório desprovido de fidedignidade recai sobre a parte que o apresenta. Em outras palavras, se a parte apresenta meio de prova cuja fidedignidade é impossível aferir, tal estratégia processual apenas beneficia a parte adversa.

Princípio da autorresponsabilidade das partes aplicado às gravações audiovisuais contida nos links de fls. 240 e imagens incorporadas às alegações finais defensivas (fls. 269/271 e 273/274).

O Defensor apresentou links (fls. 240) para duas gravações audiovisuais e fotografias (fls. 269/271 e 273/274).

Não se produziram, contudo, elementos de prova sobre a data, horário e local de produção dos vídeos e fotografias, nem sobre a identidade das pessoas retratadas e o que faziam.

Ou seja, é impossível, por meio dos elementos de prova trazidos aos autos, inferir se as fotografias retratam o local do fato ou outro, bem como se retratam um dos policiais que participou da diligência.

Conquanto os vídeos supostamente existam desde a data do crime, pois retratariam parte das buscas policiais (fls. 272/273), não foram apresentados à Autoridade Policial que presidiu a investigação.

O Defensor optou por não requerer a submissão dos vídeos e fotografias a perícia, não arrolou testemunhas das circunstâncias de produção daquelas mídias e não as exibiu às testemunhas ouvidas sob o contraditório.

Não há notícia de preservação da cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes, CPP) da mídia em que originariamente foram gravados os vídeos.

Como os vídeos e fotografias não atendem a parâmetros mínimos de fidedignidade legalmente estabelecidos, sua autenticidade não pode ser afirmada.

Em outras palavras, não é possível afirmar que os vídeos e fotografias correspondem ao objeto deste feito.

A ausência de preservação da cadeia de custódia, a insubmissão à perícia e a ausência de elementos de prova sobre as circunstâncias de produção mitigam a aptidão dos vídeos e fotografias para demonstrar os fatos alegados pelo Defensor. Autenticidade hipotética dos vídeos (fls. 240) e fotografias (fls. 269/271 e 273/274).

Ainda que se admita a autenticidade daqueles registros (vídeos e fotografias), nenhum deles infirma o relato apresentado pelas testemunhas policiais militares.

Os policiais informaram que realizaram buscas em dois terrenos. Primeiro, vistoriaram um terreno murado, onde o réu estava, e lá encontraram porções de maconha, crack e cocaína, balanças, facas e invólucros plásticos. Depois, com auxílio de cães farejadores, vistoriaram um terreno nas imediações e encontraram outras duas porções de maconha.

Os vídeos (fls. 240), supostamente, retratam apenas a segunda parte das buscas,

pois o imóvel cuja imagem foi capturada não é murado e os supostos policiais estavam acompanhados de um cão.

Portanto, ainda que sejam autênticos, os vídeos (fls. 240) são plenamente compatíveis com os relatos das testemunhas policiais militares. Isto é, retratam a segunda parte da diligência descrita pelos milicianos, consistente nas buscas com auxílios de cães.

Segundo o Defensor, os policiais não teriam condições de visualizar o acusado abaixado no interior do terreno, pois o muro é alto (fls. 271); e não seria possível fugir pelos fundos em direção à via pública, pois apenas um lado do imóvel tem face voltada para a rua (fls. 269/270).

Impossível averiguar se os ângulos de captura das fotografias de fls. 271 correspondem aos ângulos de visão que os policiais tinham. Aparentemente, parte do terreno está situado em um aclive, seu muro é irregular, com algumas partes mais elevadas que outras, e parte do muro está quebrado. Por isso, não se pode concluir que era impossível ver o réu no interior do terreno.

Além disso, o réu, no interrogatório, declarou que estava no interior do terreno e viu os policiais. Como o acusado conseguia enxergar os milicianos, estes, presumivelmente, também conseguiriam vê-lo.

Sobre a rota de fuga, o terreno destacado na imagem de fls. 270 tem forma triangular. O Defensor não solicitou que as testemunhas detalhassem a rota de fuga do acusado.

Ainda que a imagem de fls. 270 seja autêntica, ambas as testemunhas narraram a fuga do réu para a via pública. É certo que o policial Anderson, ao usar o vocábulo fundos na descrição da rota evasiva, referia-se à extremidade do muro oposta àquela por onde os milicianos estavam a ingressar.

Note-se que, segundo o policial Anderson, o muro do terreno estava parcialmente quebrado, caído, de maneira a servir como escada, circunstância compatível com as fotografias de fls. 270.

Ainda segundo o Defensor, as testemunhas policiais militares se contradisseram ao descrever a apreensão do segundo conjunto de drogas.

Conforme o policial Henrique, o segundo conjunto de substâncias entorpecentes foi encontrado a quarenta ou cinquenta metros do local da primeira apreensão. A testemunha Anderson, por sua vez, declarou que o segundo conjunto foi encontrado em terreno situado defronte ao local onde Walisson estava.

O terreno triangular contido na fotografia de fls. 274 tem uma das extremidades voltada, apontada, para um grande terreno, aparentemente ocupado pela vegetação. Essa circunstância se compatibiliza com as declarações de ambos os policiais. Isto é, o segundo imóvel está situado defronte a uma das extremidades do primeiro e, aparentemente, há amplitude, profundidade, suficiente para que esconderijo da droga estivesse a quarenta ou cinquenta metros de distância.

Portanto, é incerta a autenticidade dos vídeos (fls. 240) e fotografias (fls. 269/271 e 273/274). Ainda que se considerem autênticos aqueles elementos de prova, nenhum deles infirma os relatos das testemunhas policiais militares.

Fixadas estas premissas, passo a analisar a classificação jurídica do fato e sua autoria, à luz da prova colhida.

Análise da classificação jurídica do fato.

Conforme se expôs anteriormente, o laudo de exame químico toxicológico (fls. 126/129) demonstra a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade.

A grande quantidade e variedade de drogas apreendidas e a guarda concomitante de petrechos para o fracionamento demonstram que se destinavam ao fornecimento a terceiros.

Segundo as testemunhas policiais militares, as substâncias entorpecentes compunham dois conjuntos.

O primeiro conjunto, encontrado num terreno murado, era formado por 65 porções de maconha, 34 porções de cocaína, 05 (cinco) porções de maconha e 06 (seis) porções de cocaína.

As porções do primeiro conjunto totalizavam aproximadamente 340,64g de maconha e 99,31g de cocaína.

O acondicionamento de parte das drogas em pequenas porções individuais, retratadas às fls. 31/32 e 34, indica que as porções do primeiro conjunto se destinavam à entrega a diferentes pessoas.

Além disso, as drogas estavam junto a facas, balanças e embalagens tipo zip com resquícios de maconha e cocaína (fls. 131/134).

Segundo a testemunha Anderson, as balanças ainda estavam ligadas quando foram encontradas.

A existência de facas, balanças ligadas e embalagens (fls. 131/134) junto às substâncias entorpecentes indica que o autor do fato estava fracionando, pesando e embalando as drogas, para posterior comercialização.

O segundo conjunto, encontrado em outro terreno, era composto por 02 (duas) porções de maconha, que pesavam 358,32g.

A quantidade, que seria suficiente para confecção de centenas de porções individuais, e a guarda em área de mata, evidenciam que se destinavam à comercialização.

Ao ter em depósito substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, o autor do fato realizou a conduta abstratamente prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Passo a averiguar a autoria da infração penal.

Análise da autoria.

As declarações do réu e das testemunhas policiais militares convergiram no sentido de que Walisson estava num terreno murado. Ao ver os milicianos, ele tentou fugir pela via pública, mas foi abordado.

O acusado, no interrogatório, declarou que comparecera ao local para apanhar uma pipa de brinquedo, que vira voando desgarrada pelo céu.

Entretanto, não há prova alguma de que houvesse pipa no local.

É certo que, segundo o auto de exame de corpo de delito de fls. 54, Walisson apresentava ferimento que ele afirmou ter sido causado por linha de pipa. Todavia, segundo o mesmo auto, o denunciado declarou que sofrera o ferimento na véspera do fato, em 14/06/2022.

Quando ouvido pela Autoridade Policial (fls. 06), Walisson declarou que se tratava de um ferimento antigo.

Como a lesão (fls. 54) ocorreu em data anterior ao fato narrado na inicial acusatória, sua existência nada esclarece sobre o que o réu fazia na ocasião do crime.

Portanto, não há prova alguma da adução de que Walisson ingressou no terreno baldio para apanhar uma pipa.

Resta a versão apresentada pelas testemunhas policiais militares.

Segundo os milicianos, o denunciado estava no interior do terreno baldio, no preciso local onde posteriormente encontraram o primeiro conjunto de objetos, composto por 65 porções de maconha, 34 porções de cocaína, 05 porções de maconha e 06 porções de cocaína.

O segundo conjunto de substâncias entorpecentes, composto por 02 (duas) porções de maconha, com massa líquida de 358,32g (trezentos e cinquenta e oito gramas e trinta e dois centigramas), teria sido encontrado em outro terreno, próximo ao primeiro.

Em que pese a argumentação do Defensor, a condição profissional das testemunhas, policiais militares, não diminui o valor de seus depoimentos se não houver indícios de que tenham mentido. Neste sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

Aliás, carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie inócua. (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; proferida em 30/09/2003).



No caso, não há evidência alguma de que os policiais tenham mentido, tampouco de que tivessem motivos para tanto.

Segundo o Defensor, as testemunhas se contradisseram quanto à distância entre o local do fato e a residência do réu; e quanto à circunstância de Walisson estar abaixado no momento da chegada da viatura.

Tais aduções são irrelevantes, pois versam sobre circunstâncias marginais do fato. O policial Henrique declarou que o acusado residia no bairro onde os fatos ocorreram; e Anderson, que Walisson residia a uma quadra de distância do local do fato.

Extrajudicialmente (fls. 06), o réu declarou que residia a quatro ou cinco quadras de distância do local do fato. Sob o contraditório, afirmou que residia a três quarteirões de distância do local da prisão.

Segundo o Defensor, a distância real é de cinco quarteirões (fls. 269).

Como sequer o acusado soube esclarecer com precisão a distância entre o local do fato e sua moradia, não é razoável exigir que os milicianos o fizessem.

É irrelevante saber se o réu estava abaixado ou em pé quando a viatura policial chegou. Basta, para a elucidação da autoria, saber que estava no terreno baldio onde a maior quantidade de drogas foi encontrada.

A uniformidade entre as declarações dos policiais militares e a corroboração de seus relatos por elementos materiais, consistente na apreensão de drogas e outros objetos, demonstram que reportaram o fato fielmente.

Portanto, as declarações dos policiais militares demonstram que Walisson estava no terreno onde o primeiro conjunto de drogas e objetos foi encontrado, junto àquelas peças.

Como não haveria motivos para que comparecesse ao local e as balanças estavam ligadas, não há dúvidas de que o réu estava fracionando, pesando e embalando as drogas, consistentes em 65 (sessenta e cinco) porções de maconha, com massa líquida de 192,16g (cento e noventa e dois gramas e dezesseis centigramas), 34 (trinta e quatro) porções de cocaína, com massa líquida de 42,7g (quarenta e dois gramas e sete decigramas), 05 (cinco) porções de maconha, com massa líquida de 150,48g (cento e cinquenta gramas e quarenta e oito centigramas), e 06 (seis) porções de cocaína, na forma de crack, com massa líquida total de 56,61g (cinquenta e seis gramas e sessenta e um centigramas).

Ao ter em depósito em depósito e possuir substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento, o denunciado praticou condutas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, não há prova de que o segundo conjunto, formado por 02 (duas) porções de maconha, com massa líquida de 358,32g (trezentos e cinquenta e oito gramas e trinta e dois centigramas), também estivesse sob a posse e guarda do réu. O réu não foi visto no terreno onde o segundo conjunto de drogas foi encontrado. Não há prova de que ele, em algum momento, ingressara naquele imóvel.

Como não há prova do contato físico entre o acusado e o segundo conjunto de substâncias entorpecentes, composto por 02 (duas) porções de maconha, com massa líquida de 358,32g, é impossível afirmar que ele tinha essa droga em depósito. Outras aduções defensivas.

São irrelevantes as aduções de que não se demonstrou o comparecimento anterior do acusado ao terreno (fls. 270) e de que o celular de Walisson não tinha dados relacionados ao tráfico de drogas (fls. 270).

As evidências de que o réu estava fracionando as substâncias entorpecentes bastam para demonstrar que os bens ilícitos estavam sob a posse dele. Prescinde-se de evidência de que foi ele quem as transportou para o local do fato.

O perito não teve acesso a todos os dados do aparelho celular apreendido, mas apenas a dados do SIM Card e do cartão de memória (fls. 156). Como o perito não acessou a memória interna do smartphone, não se pode afirmar, com base no laudo de fls. 149/159, que inexistia no aparelho conteúdo relacionado ao tráfico de drogas. De qualquer forma, não se imputa ao acusado a utilização do celular na execução do crime.

Impossibilidade de desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Por estar evidenciado o tráfico de drogas, fica logicamente afastada a possibilidade de desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inaplicabilidade da diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O réu é reincidente, pois praticou o novo crime após a condenação na ação penal nº 1500360-91.2019.8.26.0583 (fls. 47/48).

A configuração da causa de diminuição de pena descrita no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 supõe a primariedade do agente. Logo, a reincidência a obsta.

Ao contrário do que alegou o Defensor (fls. 282), a reincidência é específica, pois o réu foi anteriormente condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

De qualquer forma, o óbice à diminuição de pena decorre da ausência de primariedade (reincidência), não de reincidência específica. Neste sentido:

(...) A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, pois, dentre outros requisitos, é necessária a primariedade do agente (...). (STJ; Sexta Turma; AgRg no HC 510.192/PR; Relatora: Ministra Laurita Vaz; j. 25/06/2019; DJe 02/08/2019).

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Dosagem da pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que os registros criminais anteriores do acusado ensejam reincidência, a ser sopesada adiante.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta) é elevada para esta modalidade de delito, haja vista a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a especial nocividade do crack e a posse de petrechos para fracionamento.

As circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Não há notícias desabonadoras sobre a conduta social do denunciado, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

Considerando tais elementos, fixa-se a pena-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do acusado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que o acusado é reincidente (art. 61, I, CP), pois voltou a praticar infração penal após a condenação no processo de conhecimento nº 1500360-91.2019.8.26.0583 (fls. 47/48). Por conseguinte, exasperam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase do cálculo, não está presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente.

Considerando a culpabilidade elevada e a reincidência, o denunciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivos (reincidência específica e culpabilidade elevada) e objetivo (quantum da sanção), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar WALISSON VINICIUS DE SOUZA MATOS PEREIRA, natural de Presidente

Prudente/SP, nascido aos 01/06/1999, filho de Cláudio da Silva Pereira e de Adriana Aparecida de Souza Matos, inscrito no RG nº 59.531.752 SSP/SP e no CPF nº 492.930.828-37, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

A reincidência e a culpabilidade elevada denotam o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de reiteração. Tal circunstância determina a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Tratando-se de réu tecnicamente pobre, concedo-lhe a gratuidade processual. Dessa forma, arcará com o pagamento das custas processuais, somente se houver melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que as balanças, as facas e os saquinhos apreendidos (fls. 29/30) eram usados na prática do crime. Como são bens inservíveis, autorizo sua imediata destruição.

Por não vislumbrar correlação entre a prática delitiva e o celular apreendido (fls. 29/30), autorizo sua restituição ao acusado, após o trânsito em julgado.

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensores constituídos (fls. 125).

Transitada em julgado, expeçam-se guia de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 02 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA